

1500870-19.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, quanto às 60 porções de cocaína localizadas em poder do acusado, afastando-se, ainda, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal (tráfico privilegiado), e, por outro lado, a absolvição do acusado da prática do crime de tráfico de drogas quanto às 1.030 porções de cocaína ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500870-19.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500870-19.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226766/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 26863587 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, FE8604-1/2022 - Delegacia de Polícia de Atibaia, 2226766 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO GODOY DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

ALESSANDRO GODOY DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 18 agosto 2022, no horário e no endereço mencionados na denúncia, teria trazido consigo e guardado, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 1.090 porções de cocaína (pesando aproximadamente 738g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado à fl. 125 e apresentou defesa prévia às fls. 107/112.

A denúncia foi recebida às fls. 141/145.

Citado (fls. 174), em audiência de instrução e julgamento (fls. 171), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação e duas testemunhas arroladas pela Defesa, sendo realizado o interrogatório do acusado ao final, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, requereu a integral procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos (fls. 180/195), requereu, preliminarmente, a anulação do processo em virtude de cerceamento da defesa em razão da ausência de perícia na chave e no celular apreendidos. No mérito, requereu a absolvição do réu, alegando ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais em virtude da violação de domicílio. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do acusado em decorrência da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, ainda, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, destaco que a tese de cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia na chave e no celular apreendidos, será melhor analisada adiante, quando da valoração da prova.

No mérito, de rigor a parcial procedência dos pedidos acusatórios, para o fim de declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, e todas as delas decorrentes, absolvendo-se o acusado quanto ao delito de tráfico de drogas no que concerne às 1.030 porções de cocaína apreendidas no interior do imóvel; e condenando-o, por outro lado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em relação às 60 porções de cocaína apreendidas em poder do acusado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelas fotografias de fls. 16/21, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 22/23, pelo comprovante de depósito de fls. 76, pelos laudos de exame químico toxicológico de fls. 93/95, pelo laudo pericial de fls. 101/106 (balança e adesivos autocolantes), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, com relação às 60 porções de cocaína apreendidas em poder do acusado, restou certa e segura.

Por outro lado, com relação às 1.030 porções de cocaína apreendidas no interior do imóvel, em que pese a existência de fortes indícios de autoria, haverá absolvição do réu diante do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, pelos motivos abaixo mencionados.

O réu Alessandro Godoy de Oliveira, no interrogatório realizado na fase policial (fls. 08), negou a prática do crime, aduzindo que: estava caminhando pela Rua Quatro, logo após ter ido a um ponto de venda de drogas; no local dos fatos, estava com a quantia de R\$ 150,00; na "biqueira", comprou uma porção de cocaína; pagou R\$ 20,00 pela porção; em um certo momento, avistou uma viatura da polícia militar e colocou seu boné na cabeça; em seguida foi abordado pelos agentes; um dos policiais militares perguntou se conhecia uma determinada pessoa; negou conhece-lo; o policial militar Rafael lhe disse que iria achar alguma coisa; ele disse que

encontraria algum "B.O."; no momento da abordagem, estava com a chave de sua casa pendurada no pescoço; foi questionado pelos policiais sobre a chave e disse que a chave era de sua casa; em dado momento, percebeu que um dos policiais militares se afastou, acessando a Rua 01 do bairro Santa Clara; percebeu que o policial militar, que não se recorda o nome, adentrou uma residência; acredita que a residência estava vazia; lá, ele localizou uma farta quantidade de entorpecentes; o questionaram se estava traficando entorpecentes; negou-lhes a prática delitiva; já foi, quanto menor de idade, apreendido pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas; contudo, na data dos fatos, não estava em posse de farta quantidade de entorpecente, mais apenas de uma porção destinada ao seu consumo pessoal.

Em juízo, voltou a negar o cometimento do delito, afirmando que: possui 19 anos de idade; é solteiro; não possui filhos; anteriormente à prisão, trabalhava em uma empresa metalúrgica no bairro Guaxinduba, na cidade de Atibaia; trabalhou no local por cerca de 04 meses; seu superior hierárquico era chamado pela alcunha "pequeno"; trabalhava com registro em CTPS; não possui condenações criminais; possui passagem pela Vara da Infância por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas; ficou internado na Fundação Casa por 06 meses e 08 dias; é inocente da acusação; está sendo injustiçado; na data dos fatos, estava passeando de carro com seu colega; possuía R\$ 150,00 em seu bolso; decidiram parar na "biqueira" para comprar um pino de cocaína; pararam o carro no campo; desceu do veículo e comprou um pino de cocaína; pagou pelo entorpecente a quantia de R\$ 20,00; estava subindo a Rua Quatro; avistou a viatura; seguiu subindo pela Rua Quatro; os policiais militares o abordaram e o questionaram; disse a eles que havia adquirido um pino de cocaína para consumo próprio; o revistaram e encontraram apenas um pino de cocaína; seu documento e R\$120,00; ele lhe ordenou que sentasse sobre as suas mãos; ele começou a conversar com o outro policial militar; o questionaram se conhecia a pessoa de alcunha "bruxa", tendo negado a eles; eles o disseram "você vai conhecê-lo então", "nós vamos estourar a casa dele"; disse a eles que Deus estava vendo; disse a eles que não era traficante; os dois policiais ordenaram a outro policial que ficasse no local o vigiando; eles desceram a rua e entraram em uma residência; ficou no local por cerca de 30 minutos; os transeuntes questionaram o que estava ocorrendo; o policial que estava no local telefonou aos outros policiais; o colocaram dentro do porta-malas da viatura e o levaram até a residência; questionado, informou a eles que desconhecia a residência; eles o levaram até o interior da residência e jogaram uma bolsa cheia de drogas em cima da cama; os entorpecentes que estavam no interior da bolsa eram diferentes daquele apreendido na busca pessoal; eles o questionaram quem era o proprietário do imóvel; disse a ele que desconhecia tal pessoal; eles passaram a lhe fazer perguntas difíceis, motivo pelo qual passou a ficar em silêncio; eles o ameaçaram de lhe matar; disse a eles que nãoalaria "dos outros"; eles o disseram, então, que o prenderiam; eles o colocaram na viatura e o conduziram até a delegacia; não conhecia os policiais militares anteriormente aos fatos; seu amigo não foi abordado pelos policiais porque estava o esperando no campo; o carro estava parado na rua de cima; seu colega era quem estava dirigindo; estava com seu celular; seu celular não possuía adesivos; desconhece o nome do proprietário do imóvel onde as drogas foram localizadas; a chave apreendida não estava em seu pescoço; possuía apenas uma chave em seu bolso, pertencente a sua casa, que fica na Rua Ernesto Binatti, 445, nº 48, Jardim Cerejeiras; sua chave não possuía cordão; para adentrar a residência, eles estouraram a porta; nega que tenha afirmado, na delegacia que residia na Rua Quatro; eles estão mentindo.

Tal versão dos fatos, no entanto, merece ser considerada apenas em parte pelo Juízo.

Isto porque o policial militar Douglas Rodrigues Gonçalves, em juízo, relatou que: na data dos fatos, estavam realizando patrulhamento pela Rua Quatro, no bairro Santa Clara, quando se depararam com o acusado; ele estava caminhando pela calçada no contrafluxo da viatura; ao avistar a viatura ele escondeu algo que estava em

suas mãos na cintura; realizaram a abordagem; em busca pessoal, encontraram com ele um maço de cigarro, dentro do qual havia 60 porções de cocaína; ao indagarem o acusado, ele confessou informalmente a prática delitiva; ele informou que exercia a função de gerente do tráfico; e frente ao local da abordagem havia uma casa azul; havia denúncia de que o local era ponto de tráfico de drogas; ao indagarem o acusado, ele disse que estava tomando conta da residência naquela noite, bem como que a chave do local estava pendurada em seu pescoço; segundo ele, a casa era alugada pela organização criminosa; ele disse que havia outras porções de cocaína no interior da residência; ele abriu a porta da residência; adentraram e revistaram o local; no interior do imóvel, localizaram mais de 1.000 porções de cocaína idênticas aquelas encontradas na busca pessoal; no interior da residência foram encontradas embalagens, adesivos autocolantes, bem como uma balança de precisão; a chave foi apresentada na delegacia; não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

Nesse mesmo sentido, o policial militar Rafael Rodrigues Da Silva, em juízo, narrou que: na data dos fatos, estavam realizando patrulhamento pela Rua Quatro, no bairro Santa Clara; o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas; avistaram o acusado caminhando, subindo a Rua Quatro; estavam descendo a rua, em sentido contrário a ele; ao avistar a viatura, ele colocou o objeto que estava em sua mão na cintura; realizaram a abordagem; em busca pessoal, localizaram com ele certa quantia em dinheiro e um maço de cigarro contendo 60 porções de cocaína; ele confessou informalmente a prática delitiva, afirmando que estava traficando drogas naquele local; a equipe possuía conhecimento de que a casa azul existente naquela rua era usada pela organização criminosa para guardar drogas para fins de tráfico; ao questionarem o acusado, ele afirmou residir na casa azul; ele possuía uma chave pendurada em seu pescoço; ao questionarem o acusado, ele confessou informalmente que havia outras drogas guardadas no interior da residência; ele não forneceu nome dos demais envolvidos na organização criminosa; foram até a casa; no interior da residência, na estante, localizaram o restante das drogas; lá havia mais de 1.000 porções de cocaína; no local havia, ainda, petrechos, como adesivos autocolantes, embalagens e balança de precisão; todos os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia; também encontraram documentos e a carteira do acusado no interior da residência; o acusado dormia no local e cuidava do ponto de tráfico; conduziram o acusado até a delegacia; não se recordava do acusado; na delegacia, o acusado lhe disse que já o conhecia de abordagem anterior, de quando era menor de idade; a chave utilizada para abrir a porta da residência estava pendurada em uma corrente, no pescoço do acusado; não se recorda se a chave foi apresentada na delegacia.

Já a testemunha Célia Moreira Luciano, arrolada exclusivamente pela Defesa, em juízo, aduziu que: é vizinha do acusado há cerca de 11 anos; não são amigos íntimos; não presenciou a prisão do acusado; reside na Rua Hernesto Binatti, quadra 45, nº 10; ele reside com a mãe dele, em frente a sua casa, na Rua Hernesto Binatti, nº 31; não sabe com o que ele trabalha.

Por fim, a testemunha Denair do Carmo Sampaio, em juízo, relatou que: é vizinha do acusado há cerca de 12 anos; não são amigos íntimos; ele reside com a mãe e os irmãos; já viu o acusado descer algumas vezes do veículo fretado de uma empresa que para em frente a sua casa; ele trabalha em uma empresa metalúrgica, no bairro Jarinu; não presenciou a prisão do acusado; ele reside na Rua Hernesto Binatti; reside na Rua Desembargador Felipe Pugliesi, quadra 20, casa nº 09.

Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, no que concerne às 60 porções de cocaína apreendidas em seu poder, pelos seguintes motivos: I - apreensão de relativa quantidade de entorpecentes (60 porções de cocaína); II - confissão informal do acusado aos policiais militares no momento da abordagem; III - depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu; IV - apreensão de significativa quantia em dinheiro em poder do réu (R\$ 130,00), sem comprovação de origem lícita.

Com efeito, os policiais militares Douglas e Rafael, tanto em solo policial quanto em juízo, apresentaram depoimentos coesos e verossímeis, confirmando o acusado foi visualizado, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo, ao avistar a viatura policial, demonstrado nervosismo e escondido na cintura um objeto que segurava nas mãos.

Ainda, referidos policiais militares relataram que, em revista pessoal, encontraram com ele a quantia de 60 porções de entorpecente (cocaína), no interior de um maço de cigarros, além da quantia de R\$ 130,00 em cédulas trocadas.

Como se não bastasse, narraram que o réu, no momento da abordagem, confessou informalmente que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, bem como que se destinavam ao tráfico de drogas, tendo afirmado, ainda, que exercia a função de gerente da organização intitulada "PCC".

Tal versão dos policiais militares restou em consonância com a maior parte das provas carreadas aos autos, motivo pelo qual merece credibilidade por este Julgador.

A versão do acusado, por outro lado, não merece a menor credibilidade, na medida em que sua condição de usuário/dependente químico não restou minimamente comprovada.

Nessa perspectiva, insta salientar que sequer foram arroladas testemunhas pela Defesa para comprovação de tal condição.

Nesse ponto, destaco que as testemunhas Denair e Célia, arroladas pela Defesa, limitaram-se a informar o endereço da suposta residência do acusado, bem como que não trouxeram qualquer informação acerca da suposta condição de usuário do acusado, não tendo sequer presenciado a abordagem.

Ademais, tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (60 porções de crack), não é crível que estas se destinavam à manutenção de seu suposto vício.

Nesse ponto, destaco que a versão do acusado, de que portava tão somente 01 porção de cocaína, bem como que os policiais militares imputaram a ele, falsamente, a propriedade dos demais entorpecentes (encontrados no interior do maço de cigarro), a fim de incriminá-lo, restou fantasiosa, tendo ele afirmado, em juízo, que sequer conhecia os policiais militares anteriormente aos fatos, não tendo apresentado qualquer justificativa para que eles quisessem injustamente incriminá-lo.

Outrossim, insta ressaltar que, ao contrário do quanto aduzido pela Defesa, não há falar em ausência de credibilidade no relato de servidores policiais na medida em que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de servidores policiais merece fé até prova em contrário

(RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até porque os policiais militares sequer conheciam o acusado.

De outro giro, em que pese o réu afirmar que o montante em dinheiro apreendido era proveniente do seu trabalho, devidamente registrado, em uma metalúrgica, não houve comprovação nos autos de obtenção lícita de qualquer valor.

Nesse aspecto, consigno que não foi juntado qualquer documento (tal como cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS) para comprovação da obtenção lícita dos valores apreendidos, ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia (art. 156, do Código de Processo Penal).

Consigno, ainda, o fato de o acusado ter afirmado, por ocasião da audiência de custódia (fls. 53/55) que, na data dos fatos, estava desempregado há cerca de 01 mês.

Insta salientar que este Juízo não levou em consideração as demais drogas apreendidas no imóvel (1.030 porções de cocaína), bem como os petrechos apreendidos (balança de precisão e adesivos autocolantes) consoante acima mencionado, para o fim de formar convencimento, tendo em vista a invalidade das provas obtidas por meio ilícito, cf. será analisado adiante.

Reconhecida a autoria do crime de tráfico de drogas, entendo, todavia, que o acusado não faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a sua condenação anterior, com trânsito em julgado, pela Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de drogas (cf. certidões de fls. 167/168 – Autos 1500921-98.2020.8.26.0545 e 0003423-23.2020.8.26.0048, ambos da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude desta Comarca de Atibaia, fato ocorrido em 17/08/2020, medida socioeducativa de internação revogada em 25/02/2021), circunstância esta que, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, indica efetiva dedicação a atividades criminosas.

Nesse ponto, destaco que este Juízo levará em consideração a referida condenação pela prática de ato infracional a fim de afastar o redutor, tendo em vista guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.916.596/SP, tendo sido reconhecida a possibilidade, em tese, de considerar atos infracionais como fundamento idôneo a demonstrar dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, quando contemporâneos ao delito em julgamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL E DE AÇÕES PENAIAS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou

o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). 6. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). 7. A presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, no registro de atos infracionais e na quantidade de droga apreendida não se harmoniza com a orientação predominante do STF. 8. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 613508 SC 2020/0240550-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp n. n. 1.887.511/SP.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, com relação às 60 porções de cocaína apreendidas em poder do acusado, impõe-se a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, afastando-se, ainda, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal (tráfico privilegiado).

Por outro lado, no que concerne às 1.030 porções de cocaína apreendidas no interior do imóvel, embora devidamente comprovada a materialidade delitiva e a existência de fortes e suficientes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, entendo ser o caso de acolhimento da tese Defensiva, declarando-se a invalidade das provas obtidas mediante a violação do domicílio do acusado.

Com efeito, não ignora o Juízo a credibilidade que merece o depoimento de policiais militares, mormente quando se revelam-se coesos e verossímeis, como no caso em tela.

Nessa perspectiva, saliento que o depoimento dos policiais militares não deixa dúvidas quanto à localização de elevada quantidade de entorpecentes no interior da residência (1.030 porções de cocaína), além de uma balança de precisão e adesivos autocolantes.

Contudo, considerando recentíssima jurisprudência dos C. Tribunais Superiores (STJ e STF), em que pese posicionamento contrário há muito adotado por este Juízo e sem prejuízo de maior reflexão oportuna, caso as Cortes Superiores façam alguma modulação dos efeitos das decisões, só resta reconhecer a invalidade das provas obtidas na busca domiciliar efetuada pelos policiais militares em virtude da existência de violação, no caso concreto, às regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio.

O plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/R0, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que

naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

Por sua vez, a 3ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos HCs nº 598.051 (julgado pela 5ª Turma) e 616.584 (julgado pela 6ª Turma), unificou o entendimento no sentido de que cabe ao Estado demonstrar, de modo inequívoco - inclusive por meio de registro escrito e de gravação audiovisual -, o consentimento expresso do morador para a entrada de agentes policiais em sua residência, quando não houver mandado judicial. Ainda, na hipótese de estar ocorrendo crime no local - o que permitiria o ingresso sem autorização do morador sem ordem judicial -, os agentes também devem comprovar essa situação excepcional.

Pois bem. Diante dos precedentes acima referidos, mormente das diretrizes que foram estipuladas para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, em que pese o posicionamento contrário, até então, deste Juízo e também de muitas Câmaras Criminais do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (crime permanente; consumação do delito que se prolonga; suficiência dos indícios de autoria através de denúncia anônima ou outro elemento de prova; suficiência da autorização informal de qualquer morador da casa para o ingresso na casa), dúvidas não restam de que, in casu, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e, por conseguinte, de toda a prova dela decorrente.

Isto porque, considerando que, no caso concreto, inexistiam fundadas razões de que no imóvel onde foi realizada a busca estava ocorrendo a prática de delito, não sendo suficiente a mera existência de denúncia anônima envolvendo o imóvel em questão.

Vale ressaltar que não há menção, por exemplo, a "campana" próxima à residência para verificar a movimentação na casa e outros elementos de informação que pudessem ratificar a notícia anônima.

Verificada, portanto, a insuficiência de tais elementos para caracterizar a "justa causa" exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. 2. Não tendo sido realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos que confirmassem a suspeita levantada por telefonema anônimo, é ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio." [...] (STJ - RHC: 101797 SP 2018/0205190-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 234G (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA, 70G (SETENTA GRAMAS) DE CRACK E 151G (CENTO E CINQUENTA E UM GRAMAS) DE COCAÍNA E ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ORDEM CONCEDIDA. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 234g (duzentos e trinta e quatro gramas) de maconha, 70g (setenta gramas) de crack e 151g (cento e cinquenta e um gramas) de cocaína, além de arma de fogo -, quando apoiado em mera denúncia anônima, não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado

judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Ordem concedida para anular as provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio." (STJ - HC: 528729 SP 2019/0249360-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

Nesse viés, cabia, ainda, aos agentes estatais (in casu, policiais militares) fazerem prova inequívoca de que o ingresso na residência ocorreu com o consentimento do réu Alessandro, o que não se verificou na hipótese presente.

Nessa linha, destaco que, tanto em solo policial (fls. 06) quanto em juízo, o acusado negou que tivesse autorizado o ingresso dos policiais militares na residência, tendo afirmado que sequer residia naquele imóvel e, ainda, que a chave que trazia consigo, pendurada em seu pescoço, era relativa à outra residência, localizada na Rua Hernesto Binatti, nº 31.

Ainda, em que pese o fato de o acusado ter afirmado, em seu interrogatório realizado na fase policial (fls. 08), que residia no imóvel em questão (Rua Quatro, nº 60), bem como o fato de os policiais militares terem aduzido, de forma coesa e verossímil, em ambas as fases procedimentais, que o acusado afirmou residir no imóvel, bem como que autorizou o ingresso da equipe policial no local, fornecendo, ainda, as chaves para ingresso na residência, é certo que os policiais militares não fizeram qualquer registro de seu consentimento, quer seja por escrito, quer seja por meio de gravação audiovisual (tal como decidido pela 3ª Seção do C. STJ).

No mais, destaco que não houve a apreensão da referida chave, pelos policiais, bem como que, apesar de o policial militar Rafael ter afirmado, em juízo, que os documentos do acusado foram encontrados no interior da residência, tal fato não foi mencionado por nenhum dos policiais militares na fase policial, nem confirmado pelo outro policial, em juízo.

Nesse ponto, destaco que, quanto à ausência de apreensão e perícia na chave do imóvel, a fim de se verificar se de fato pertencia ao imóvel em questão, insta sublinhar que não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da invalidade das provas obtidas no ingresso à residência, tendo tal diligência restado irrelevante ao deslinde dos fatos, no caso concreto.

De igual modo, a ausência de perícia no aparelho celular do acusado, a fim de demonstrar que ele não residia no imóvel localizado na Rua Quatro, de igual modo, em nada prejudicou a Defesa, diante da invalidade das provas obtidas no ingresso à residência.

Por tais motivos, de rigor o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e, conseqüentemente, de toda a prova dela decorrente, de forma a se absolver o acusado do crime de tráfico de drogas, quanto aos entorpecentes encontrados no interior do imóvel.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, quanto às 60 porções de cocaína localizadas em poder do acusado, afastando-se, ainda, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal (tráfico privilegiado), e, por outro lado, a absolvição do acusado da prática do crime de tráfico de drogas quanto às 1.030 porções de cocaína apreendidas no interior do imóvel localizado na Rua Quatro, nº 60.

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas, passo, pois, à fixação da pena.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, verifico que as

circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo vista a natureza (cocaína) e a relativa quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 60 porções). Além disso, levo em conta a apreensão de relativa quantia em dinheiro (R\$ 130,00), sem comprovação de origem lícita. A prática dos atos infracionais (equiparados ao delito de tráfico de drogas) – circunstância desfavorável relacionada à personalidade – foi levada em consideração apenas na 3ª fase, a fim de afastar o redutor do tráfico privilegiado. Assim, elevo a pena mínima em 1/6, perfazendo a pena-base 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante genérica da menoridade relativa (o acusado possuía 18 anos de idade na data dos fatos), de forma que reduzo a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), uma vez que tal atenuante não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo, nos termos da súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça. Não houve confissão. No mais, destaco que o acusado é primário, cf. pesquisa SIVEC de fls. 49 e certidões de fl. 50/51.

Finalmente, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, observando-se que o acusado não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos motivos supramencionados.

Torno definitiva a pena acima fixada, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquelas genericamente fornecidas por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficientes para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o semiaberto, haja vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Destaco, ainda, que, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são totalmente desfavoráveis, incabível se mostra, no caso concreto, a fixação do regime inicial fechado, com fundamento na Súmula 440, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que não se mostra cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena aplicada ao réu (superior a 04 anos) – art. 44, inc. I, do Código Penal. Ainda, de se observar que tal medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso – requisitos subjetivos (art. 44, inc. III, do Código Penal).

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (o acusado se encontra preso preventivamente há, aproximadamente, dois meses), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constantes da ação penal proposta pelo Ministério Público contra ALESSANDRO GODOY DE OLIVEIRA e assim o faço para: I) CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial semiaberto, sem conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e sem o direito de recorrer em liberdade; II) DECLARAR A INVALIDADE das provas obtidas mediante

violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, ABSOLVENDO-O, da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, quanto às 1.030 porções de cocaína apreendidas no interior do imóvel localizado na Rua Quatro, nº 60, com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao estabelecimento prisional no qual o acusado se encontrado detido a fim de que promova a adequação ao regime inicial ora fixado (semiaberto).

Após o trânsito em julgado:

I) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos);

II) oficie-se ao FUNAD com relação ao numerário depositado a fls. 76, cuja perda ora decreto, haja vista ter restado comprovada a origem ilícita do montante; e

III) oficie-se ao Setor de Armas e Objetos local para que promova a devida destinação com relação ao aparelho celular apreendido (fls. 14/15), ou, se o caso, à Central de Custódia do Instituto de Criminalística de Bragança Paulista; e

IV) quanto aos demais objetos apreendidos - no interior do imóvel (balança de precisão e adesivos autocolantes), não havendo nos autos informações acerca do proprietário dos referidos bens, decorrido o prazo a que se referem os artigos 122 e 123, ambos do Código de Processo Penal, caberá ao setor de objetos local dar a devida destinação, na forma dos dispositivos legais acima mencionados.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por Defensor constituído (Procuração de fls. 113/114), presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal despesa. Não houve, além disso, juntada de qualquer documento indicativo da sua miserabilidade, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, certidão imobiliária, carteira de trabalho ou certidão da Ciretran.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA